



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2019.0000465125

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1037984-91.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FLAVIA GUGLIELMINETTI, é apelado CARLOS EDUARDO SANCHEZ FUZARO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação, por votação unânime.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.

São Paulo, 10 de junho de 2019

HAMID BDINE

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Voto n. 20.843 – 19ª Câmara de Direito Privado.

Ap. n. 1037984-91.2016.8.26.0114.

Comarca: Campinas.

Apelante: FLAVIA GUGLIELMINETTI.

Apelado: CARLOS EDUARDO SANCHEZ FUZARO.

Juiz: André Pereira de Souza.

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO PARENTAL. DENUNCIACÃO CALUNIOSA. FALSA ACUSAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Autor que afirma ter sido ofendido em sua honra pela ré ao lhe ser imputada a prática de crime de estupro contra a filha comum das partes. Lavratura de boletim de ocorrência que deu origem à medida protetiva de afastamento do autor do convívio com a menor e ação civil para destituição do poder familiar. Ausência de abuso de direito. Inexistência de provas de que a ré agiu com o intuito de prejudicar o autor. Fatos descritos à autoridade policial que tinha amparo em relatório médico psiquiátrico com forte suspeita de que o réu tivesse abusado de sua filha. A falta de provas para a denúncia penal ou para a procedência da ação civil não torna a conduta da ré ilícita. Mãe que agiu na defesa da integridade física e emocional da filha de apenas três anos de idade diante da suspeita de um crime que tem como cenário preponderante o ambiente familiar. Dano moral não reconhecido. Condenação afastada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. Redistribuição segundo o resultado do julgamento. Sentença reformada. Recurso provido.

A r. sentença de fs. 183/189, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar a ré ao pagamento de R\$95.400,00 à título de reparação de danos morais sofridos pelo autor, bem como a condenou ao pagamento das verbas de sucumbência.

Inconformada, a ré apelou. Pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória exercida pelo autor. Sustentou que não praticou qualquer ilícito civil como fundamento para afastar o dever de indenizar. Requereu,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

subsidiariamente, a redução da condenação.

Apelação tempestiva (fs. 190 e 195) e regularmente processada com preparo (fs. 231) e contrarrazões (fs. 234/269).

Com oposição ao julgamento virtual (fs. 277).

É o relatório.

O recurso merece acolhimento.

A instauração de inquérito policial, com consequente atuação do Conselho Tutelar e do Ministério Público, para apuração de crime de estupro de vulnerável de autoria do apelado contra sua própria filha, após notícia do delito realizada pela apelante, e o ajuizamento de ação civil visando à destituição do poder familiar como resultado direto do processo administrativo penal, acarretam inegável dano a quem é apontado como autor desse grave delito que o sujeita à destituição do poder familiar e por isso ofende a dignidade do apelado.

Contudo, a indenização correspondente só é devida se houver má-fé ou abuso na comunicação do fato aparentemente criminoso à autoridade. Do contrário, a mera comunicação do fato não caracteriza ilícito, mas sim exercício regular de direito, tal como previsto no art. 188, I, do CC.

Limita-se a controvérsia em saber se estão presentes os requisitos legais para a configuração da responsabilidade civil



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

extracontratual da apelante e, caso afirmativo, definir o montante devido para o fim de reparar os danos morais sofridos pelo apelado.

Está demonstrado nos autos que as partes eram casadas até 2008, quando se divorciaram. Na ocasião, foi definido o regime de visitas da filha do casal a ser observado pelo apelado, considerando que a agravada detinha a guarda da criança que, na época, tinha pouco mais de um ano.

Segundo a petição inicial, a apelante, inspirada por “sentimento de vingança” (fs. 4), tinha como objetivo prejudicar o convívio entre o apelado e a menor.

Em 13 de março de 2011, em nova tentativa de visitar sua filha, o apelado tomou conhecimento de que fora acusado da prática de estupro de vulnerável contra a criança, conforme boletim de ocorrência n. 638/2011, de 21 de fevereiro de 2011 (fs. 62/64).

Visando à proteção de uma criança de apenas 3 anos, as visitas do apelado foram suspensas, o que interrompeu o convívio com a filha.

Conforme a causa de pedir, o exame médico realizado pela menor no Instituto Médico Legal e os acompanhamentos psicossociais das partes envolvidas não demonstraram a ocorrência do crime imputado ao apelado. Após requerimento do Ministério Público, o inquérito policial foi arquivado.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

O apelante também afirma que a ação de destituição do poder familiar promovida pelo Ministério Público em que figurou como réu, tramitou de 9 de agosto de 2011 e foi extinta em 23 de abril de 2015, quando transitou em julgado.

O apelado destacou a perda de emprego e o fato de ter deixado de conviver com sua filha por 5 anos, como consequência da acusação feita pela apelante.

Ao contestar, a apelante apresentou relatórios médicos realizados no âmbito do Conselho Tutelar em que constavam fortes indícios de que a menor era vítima de abuso sexual, o que legitima sua conduta de proteção da filha e, assim, afasta qualquer ilícito civil.

Nesse contexto, a ausência de provas para condenação do apelado no âmbito criminal ou mesmo a improcedência do pedido de destituição do poder familiar não pode, automaticamente, determinar a responsabilidade civil da apelante.

É necessário, como visto, verificar se existiu má-fé ou abuso na comunicação do fato criminoso.

Embora sejam prejudiciais as consequências para o apelado no que se refere ao longo período de não convivência com a filha por cinco anos e à qualificação de pedófilo em seu meio social, não se verifica, no caso, o abuso de direito reconhecido pela r. sentença previsto no art. 187 do CC.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Alexandre Guerra leciona que “o exercício do direito será considerado um ato reprovado pelo sistema jurídico desde que exceda a um dos limites legais” e apresenta a definição de tais limites, amparado em **Francisco Amaral**, para quem:

“deve-se entender como fim econômico ou social a função instrumental própria de cada direito subjetivo, a qual justifica a sua atribuição ao titular e define o seu exercício. Tal concepção parte da ideia de que os direitos subjetivos são instrumentos jurídicos para a realização de interesses.

A boa-fé entende-se do ponto de vista psicológico e do ponto de vista ético. Psicologicamente, a boa-fé é a convicção de que se procede com lealdade, com certeza da existência do próprio direito, donde a convicção da licitude do ato ou da situação jurídica.

Eticamente, a boa-fé significa a consideração, pelo agente, dos interesses alheios, ou a imposição de consideração pelos interesses legítimos da contraparte como dever de comportamento. Bons costumes significam o conjunto das regras morais aceitas pela consciência social, correspondendo à moral objetiva, ao sentido ético imperante na comunidade social” **(Responsabilidade Civil por Abuso do Direito, Saraiva, 2011, p. 163/164).** (realce não original)

O MM Juiz concluiu que as imputações feitas foram infundadas, qualificando-as como “desarrazoadas e sem fundamento” que demonstrassem que “a menor [era] vítima de violência sexual pelo pai [apelado]” (fs. 186).

Respeitado entendimento contrário, não há nenhuma evidência nos autos de que a apelante tenha agido com espírito emulativo, com má-fé, ao se valer da vingança apontada pelo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

apelado como mote para a realização das denúncias que resultaram nas medidas protetivas e o afastamento do convívio com a criança.

O abuso sexual, do qual a criança teria sido vítima, foi pautado em fundada suspeita, o que levou a apelante a noticiar o fato à autoridade policial.

Importante destacar que a maioria dos abusos sexuais são praticados no seio familiar (<https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/maioria-dos-casos-de-violencia-sexual-contras-criancas-e-adolescentes-ocorre-em-casa-notificacao-aumentou-83.ghtml>; e https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/10/internacional/1523370389_359276.html).

Ao tempo da notícia do crime à autoridade policial, a criança contava com apenas **três anos de idade** (fs. 36 e 62/64).

Não é necessário esforço para se reconhecer que a conduta da apelante decorre de preocupação com o cumprimento do dever, legal e moral, de assegurar à filha o pleno desenvolvimento sadio contra eventuais condutas e comportamentos de quaisquer pessoas, o que inclui o pai, ora apelado.

O boletim de ocorrência foi lavrado em 21 de fevereiro de 2011, ocasião em que foi relatado que a criança apresentava um comportamento anormal, o que motivou o encaminhamento dela ao psicólogo. Diz que ela participava de brincadeiras “fora do normal”, como aquela em que a menor “era um



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

carrinho e o papai [apelado] é uma bomba de gasolina” referindo-se ao “bumbum” e ao “pipi do papai”. Consta da descrição que essa brincadeira deveria ser “segredo” e que a criança “não quer mais as brincadeiras do carrinho” (fs. 62).

No dia seguinte à notícia do crime, o médico do IML, ao examinar a menor, descartou a ocorrência de “conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso” (fs. 74).

Apesar disso, os acompanhamentos psiquiátricos indicavam o risco de a criança estar sujeita a abuso sexual.

Em 7 de julho de 2011, a médica relatou as ocorrências em entrevistas em maio e junho anteriores (fs. 153/156).

Por ocasião da retomada das visitas paternas, a filha do casal confirmou que o apelado “não faz mais brincadeiras chatas”, “que machucava” ou “ruins”. A criança, segundo a profissional Suely Cabral, descreveu que: (I) “papai [apelado] brincava de posto de gasolina: se punha de quatro e dizia que o papai vinha por trás e depois ficava com dores nas costas”; (II) “colocava a almofada cobrindo os genitais e dizia que sai uma aguinha do papai”; e (III) “houve brincadeiras erotizadas com a criança até meados de fevereiro de 2010” (fs. 155).

Explicou, ainda, que em virtude da “retomada das visitas em maio de 2010, o pai [apelado] provavelmente se dando conta de que os comentários da criança chegaram até os adultos que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

a cercam, mudou seu repertório reforçando ainda com a criança que para garantir a continuidade dos encontros seria importante que ela afirmasse que ele não lhe fizera nenhum mal” (fs. 156).

De acordo com o relatório médico de 19 de outubro de 2011, foi revelado o comportamento da menor que retratava o “erotismo entre os bonecos que representam a família, esfregando aos pares uns contra os outros”, assim como “seus desenhos refletiam a superestimação do elemento fálico”. Nele foi descrito que o apelado “mudou rapidamente seu comportamento” ao se dar “conta de que seu comportamento era inadequado” (fs. 151).

Na ocasião a profissional concluiu que: (I) apesar de a criança negar, “confirma que houve 'brincadeiras chatas e/ou ruins' e que agora não ocorrem mais”; (II) o apelado esforçava-se para convencer que a apelante queria seu mal; (III) “a criança fica confusa, pois deve sentir saudades e necessidade do pai, mas as relações estão perturbadas, o que a deixa ansiosa sem saber como expressar seus sentimentos” (fs. 151).

E mais, observou que a criança tinha interesse “intensificado pelos contatos físicos, buscas de contato boca a boca e jogos masturbatórios com almofadas ou outros objetos com o mesmo fim” (fs. 152).

Depois de produzidas provas complementares, somente em 11 de dezembro de 2012, o Ministério Público definiu que o “elenco probatório” era frágil e não havia justa causa para a denúncia (fs. 77).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Da análise dos documentos não se extrai má-fé ou exercício abusivo de direito por parte do apelante com o intuito de prejudicar o apelado.

O fato de o médico do IML não confirmar “conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso” (fs. 74) não torna a investigação do crime infundada. Ainda persistiam fortes indicativos de que a filha era vítima de abuso sexual.

Isso porque os fatos descritos pela criança e que foram retratados à autoridade policial, dando origem, inclusive, à ação civil de destituição do poder familiar, foram confirmados pela médica psiquiatra.

Somente o laudo de 2 de maio de 2016, na ação de regulamentação de visitas promovida pelo apelado em face da apelante e com a criança com quase dez anos de idade, foi descrito que a menor “não demonstra insatisfações e também não faz queixas dos contatos com o pai” e por isso não identificou “nenhuma ocorrência ou indício que possam justificar a interrupção das visitas paternas” (fs. 115/122).

Frise-se que o tempo de afastamento do apelado é decorrência lógica do trâmite processual até que se chegasse à conclusão de que não houve crime nem fundamento para a destituição do poder familiar do apelado em ação civil promovida pelo representante do Ministério Público.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Não há evidências de que a apelante tenha contribuído para, de modo infundado, prejudicar o apelado. Inexiste demonstração de abuso de direito.

A informação relatada à autoridade policial não era, ao seu tempo, sabidamente incorreta. O que permite o reconhecimento da culpa é atribuir ao apelado fato ilícito sabidamente falso. Neste sentido:

“A comunicação da suspeita de crime à autoridade policial não é apenas um direito da vítima, é também um dever de todo cidadão, a quem compete colaborar na 'persecution criminis' e na apuração da verdade em torno das condutas suspeitas ou prenunciadoras de ilicitude penal.

Quando, porém, a acusação é maldosa ou leviana, torna-se abusiva a provocação da atuação dos órgãos repressivos da delinquência e, pelos reflexos altamente negativos que produz, o seu efeito jurídico imediato, para o agente, é uma sujeição à responsabilidade civil de indenizar o dano moral acarretado à vítima da imputação infamante”
(Humberto Theodoro Júnior, Comentários ao novo Código Civil, vol. III, tomo II, p. 631, Forense, 2003)

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

“Não comprovado o abuso de direito, não há obrigação de compensar o dano (art. 187 do Código Civil).

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica à espécie: 'para que se viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano moral seja comprovado, mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento se deu de forma injusta, despropositada, e de má-fé' (REsp 592811/PB, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Turma, julgado em 6.4.2004, DJ 26.4.2004 p. 172; REsp 592.811/PB, DJ 26.04.2004, REsp 494867/AM, DJ 29.09.2003; REsp 470365/RS, DJ 01.12.2003; REsp 969.097/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 17/12/2008).

Apenas a deliberada intenção de prejudicar, dando ensejo à investigação criminal, por fatos sabidamente falsos, importa na obrigação de compensar dano moral, o que não se vislumbra no caso.” (**Ap. n. 1000881-26.2016.8.26.0704, rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 24.8.2018**).

“Não há, no caso concreto, prova da culpa ou do dolo gerador da responsabilidade civil pelos danos ocasionados com a comunicação de fatos à autoridade policial, razão pela qual era de rigor a improcedência do pleito indenizatório.

Conforme bem salientado pelo Juízo a quo, 'ninguém está imune a ter contra si uma investigação criminal, motivo pelo qual tal fato não pode ser encarado como um dano propriamente' (fls. 136).

A punição na esfera cível daquele que leva fato à autoridade para investigação, de fato, deve ser excepcionalíssima, abarcando casos em que haja a deliberada intenção de macular a honra de outrem. Do contrário, estar-se-ia a inviabilizar de forma clara a própria atividade de persecução policial, essencial para a manutenção da harmonia Estatal.” (**Ap. n. 1001749-87.2014.8.26.0020, rel. Des. Rosângela Telles, j. 2.10.2017**).

“Como se sabe, da simples *notitia criminis* em si mesma considerada, por si só, não decorre automaticamente a responsabilidade civil do denunciante.

Faz-se necessário demonstrar que dolosamente a suposta vítima de ilícito teria dado causa à indevida apuração de fatos que rotulava como criminosos.

Isto, contudo, não se viu no caso concreto, havendo mínimos indícios de algo irregular quando a genitora resolveu tornar público eventual vulneração da integridade física e sexual da filha menor.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Relatos testemunhais (fls. 30/31) bem assim relatório emitido pela médica pediatra da menor (fls. 32) traziam um mínimo de verossimilhança aos gestos adotados pela genitora com o registro de Boletim de Ocorrência Policial e postulação de suspensão de visitas junto ao Juízo da Família.

Vê-se, neste contexto, ter havido exercício de regular direito por parte da requerida, a qual ao suspeitar da vulneração de sua filha, comunicou o fato e as circunstâncias da suposta ocorrência à Autoridade Policial e ao juízo no qual haviam sido definidas visitas.

Em verdade, ao contrário do quanto sustentado pelo apelante, nada indicava que tivesse a requerida caluniado o autor ou mesmo propagado de maneira temerária a suspeita de que teria havido abuso sexual do pai em relação à filha menor.” **(Ap. n. 0025188-59.2012.8.26.0071, rel. Des. Alexandre Bucci, j. 25.10.2016).**

Deve prevalecer o exercício regular do direito de uma mãe que visou à defesa da integridade física e emocional de sua filha de apenas três anos de idade, sobretudo, contra o pai, ora apelado. Isso porque se sabe que crimes dessa natureza têm como cenário preponderante o ambiente familiar.

Logo não há má-fé da apelante. Recorde-se que ausência de evidências que confirmassem a ocorrência do crime somente foi apurada ao final do processo administrativo penal com consequência direta para a improcedência do pedido de destituição do poder familiar.

Assim, a falta de justa causa para a denúncia penal ou de provas para a destituição do poder familiar não se confundem com acusação infundada que, esta sim, resultaria na responsabilização civil da apelante.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Assim, fica reformada a r. sentença, para afastar a condenação imposta à apelante por ausência de provas de que tenha agido com má-fé ao imputar ao apelado fatos sabidamente falsos.

Diante do resultado do julgamento do recurso, a apelada deverá arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com o dos honorários advocatícios, igualmente fixados em 10% do valor da causa, ressalvado o fato de o apelado ser beneficiário da gratuidade de justiça (fs. 128).

Registre-se, por oportuno, que eventual oposição de embargos de declaração com o intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração com esta finalidade específica (**Súmulas 211 do STJ e 282 do STF**).

Diante do exposto, **DÁ-SE** provimento ao recurso.

Hamid Bdine
Relator